

TRIBUNAL PLENO DE 30/10/2024

ITEM Nº 1

Processo: TC-019767.989.24-7

Representante: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.

Representada: Prefeitura de Alumínio

Responsável: Antonio Piassentini (Prefeito)

Assunto: Representação em face do edital do Pregão Presencial nº 25/2024, visando à constituição de “registro de preços para o fornecimento parcelado de gêneros estocáveis”.

Valor estimado: R\$ 2.689.712,88

Sessão Pública: 26/09/2024

Advogados: Luis Henrique Garcia (OAB/SP nº 322.822); Bruno Ferreira Lima Bosco (OAB/SP nº 312.600).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. RESERVA ILEGAL À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. RECOMENDAÇÃO. DETERMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

RELATÓRIO

Em exame representação formulada por **Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.** em face do edital do Pregão Presencial nº 25/2024¹, instaurado pela Prefeitura de Alumínio, visando à constituição de “registro de preços para o fornecimento parcelado de gêneros estocáveis”, com sessão pública inicialmente designada para 26 de setembro de 2024.

¹ Processo Administrativo nº 32/2024.

Contesta a representante o fato de o certame estar direcionado à participação restrita de Microempresas - ME's e Empresas de Pequeno Porte - EPP's, ao argumento de ser prejudicial ao interesse público, tendo em vista que mencionadas espécies de sociedades empresárias não possuem condições de ofertar melhores preços, "devido a diversos fatores como economia de escala, poder aquisitivo, relações comerciais com fornecedores, dentre outros".

Afirma que, dentre os 94 (noventa e quatro) itens licitados, 8 (oito) ultrapassam o limite legal de valor (R\$ 80.000,00²) que autorizaria o processamento de licitação exclusivamente em favor de ME's e EPP's:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
2	PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO	7.020	R\$ 23,76	R\$ 166.795,20
7	FEIJÃO CARIOQUINHA	14.060	R\$ 8,90	R\$ 125.134,00
9	ARROZ LONGO FINO	35.060	R\$ 7,81	R\$ 273.818,60
46	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	1.582	R\$ 51,51	R\$ 81.488,82
48	CACAU EM PÓ 100%	1.610	R\$ 70,80	R\$ 113.988,00
62	EXTRATO DE TOMATE	9.010	R\$ 13,20	R\$ 118.932,00
64	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	5.026	R\$ 32,89	R\$ 165.305,14
85	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM AÇÚCAR	5.244	R\$ 42,72	R\$ 224.023,68

Requer, assim, seja reconhecida a procedência da representação, determinando-se à Administração de Alumínio a adoção de providências saneadoras.

Decisão preliminar de 23 de setembro de 2024³ – **referendada por este E. Plenário, em sessão ordinária de 25 de setembro de 2024** – determinou a suspensão cautelar da licitação, notificando-se o responsável pelo Órgão Licitante a apresentar razões de defesa e documentação de interesse.

À míngua de pleito específico, a **Prefeitura de Alumínio**⁴ reconhece o equívoco na construção do texto editalício, orientado à participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, bem

² Oitenta mil reais.

³ Publicada no D.O.E. de 26 de setembro de 2024.

⁴ Evento 36.1.

como informa ter emitido comunicado de correção da falha, porém, não publicado em tempo hábil.

Ante os elementos e documentos coligidos pelo Órgão Licitante, mormente o reconhecimento do vício editalício seguido de medida corretiva, **Assessoria Técnico-Jurídica**⁵ conclui pela **procedência** da representação, acompanhada por respectiva **Chefia**⁶, sem embargo de considerar necessária a republicação do edital, haja vista “que as alterações [procedidas pela Origem] afetam a formulação de propostas pelas licitantes”.

Embora também opine pela **procedência** da matéria, no entender do **Ministério Público de Contas**⁷, “a retificação anunciada não deixa claro se todos os itens serão abertos à ampla participação ou apenas aqueles cujo valor estimado ultrapasse R\$ 80 mil. Assim, deve a Municipalidade se atentar ao entendimento firmado sobre a matéria nos autos das Consultas TC-025129.989.20-8, TC-025128.989.20-9 e TC-025130.989.20-5, no sentido de que, em licitação dividida em itens ou lotes, deve ser adotada a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte em relação aos itens ou lotes cujo valor seja igual ou inferior a R\$ 80 mil”.

Diante disso, sugere recomendação à Administração Municipal para que observe o entendimento firmado nos autos das Consultas TC-025129.989.20-8, TC-025128.989.20-9 e TC-025130.989.20-5, na parte que delimita a participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a itens ou lotes com valor igual ou inferior a R\$ 80.000,00 e prestigia a reserva de cota de 25% do objeto a indigitados tipos societários.

Propõe, ainda, orientação ao Executivo de Alumínio para que reavalie a adoção do sistema de registro de preços, tendo em vista que, na sua concepção, o objeto licitado é passível de quantificação e entrega em período certo ou previsível.

GCMAB / LMN

⁵ Evento 46.1.

⁶ Eventos 46.2 e 46.3.

⁷ Evento 51.

TC-019767.989.24

VOTO

MÉRITO

A instrução dos autos denota ambiente propício ao julgamento de procedência da representação, ante incontroverso vício de legalidade identificado no edital do Pregão Presencial nº 25/2024 (deflagrado pela Prefeitura de Alumínio), traduzido pela reserva de participação exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, especialmente em relação a 8 (oito) itens com valor individual acima do limite legal autorizador do tratamento diferenciado⁸, de R\$ 80.000,00⁹.

A Representada reconheceu mencionado defeito no ato convocatório, tanto que divulgou em seu site institucional o seguinte comunicado:

“REF.: PPRP 25/2024 – Processo 32/2024.

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios estocáveis:

1 - Desconsiderar o item abaixo do edital acima mencionado:

4.1.1 No edital, no item Todos os itens serão de participação exclusiva para ME, EPP ou Equiparadas, do ramo de atividades pertinentes ao objeto da Contratação, que preencherem as condições de credenciamento constante neste edital. Portanto o PPRP 25/2024

⁸ Excerto da Lei Federal nº 11.488/2007:

Art. 34 - Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, o disposto nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da referida Lei Complementar.

Excerto da Lei Federal nº 123/06:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: [...]

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

⁹ Oitenta mil reais.

– Processo 32/2024 é destinado à Ampla Participação das empresas, pois o valor estimado ultrapassa o limite para participação exclusiva de ME e EPP.”

Por razões desconhecidas, o Órgão Licitante não logrou êxito em publicar a tempo a versão corrigida do caderno de convocação, resultando, assim, na protocolização da representação em apreço, com consequente decreto de suspensão cautelar do torneio¹⁰.

Na concepção de ATJ, a medida retificatória é suficiente a sanar o vício, muito embora considere necessária a republicação do edital, porquanto “as alterações [procedidas pela Origem] afetam a formulação de propostas pelas licitantes”.

Para o MPC, contudo, “a retificação anunciada não deixa claro se todos os itens serão abertos à ampla participação ou apenas aqueles cujo valor estimado ultrapasse R\$ 80 mil”.

Nessa perspectiva, e ante a via de cognição estreita que caracteriza o rito de exame prévio, caso o Município de Alumínio, em novo edital, identifique a justificada ocorrência de hipóteses excludentes do tratamento diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte previstas no artigo 49, incisos II e III, da Lei Complementar nº 123/06¹¹, de

¹⁰ Conquanto não caiba a esta Corte a apreciação de minutas, haja vista que poderia caracterizar indevida assessoria, escrutínio da nova redação editalícia (evento 36.2) confirma a verossimilhança das alegações do Executivo Municipal e indica a **exclusão** de textos e cláusulas constantes no edital anterior (Itens 4.1, 4.1.1 e 4.1.2) que faziam referência à exclusividade de participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a “todos os itens licitados”:

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação as empresas (pessoas jurídicas) legalmente constituídas e estabelecidas anteriormente à data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compatível com o certame, e que atenderem às exigências deste edital e seus Anexos.

4.1.1. Todos os itens serão de participação exclusiva para ME, EPP ou Equiparadas, do ramo de atividades pertinentes ao objeto da Contratação, que preencherem as condições de credenciamento constante neste edital.

4.1.2. Quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempreendedor, microempresas ou empresas de pequeno porte capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório nos itens exclusivo, o Pregoeiro convocará as demais licitante(s) para participar(em) deste item, conforme art. 49, inciso II da Lei Complementar 123/06.

¹¹ Excerto da Lei Complementar nº 123/06:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. [...]

Art. 49. Não se aplica o disposto nos [arts. 47 e 48 desta Lei Complementar](#) quando: [...]

mister que estas sejam registradas nos documentos técnicos correlatos à licitação (Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência), de sorte a legitimar eventual amplitude conferida à disputa, por ocasião da versão retificada do ato convocatório¹².

Em não ocorrendo nenhuma das referidas hipóteses excludentes e considerando que, dentre os 94 (noventa e quatro) itens licitados, somente 8 (oito)¹³ possuem valor estimado superior ao limite legal autorizador (R\$ 80.000,00¹⁴) para o emprego de licitação destinada exclusivamente para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverá atentar-se não só para a previsão do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/06¹⁵, mas também para o comando normativo do respectivo inciso III¹⁶, dispositivo legal que impõe o estabelecimento de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

¹² Extrato da versão retificada do edital do Pregão Presencial nº 25/2024:

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação as empresas (pessoas jurídicas) legalmente constituídas e estabelecidas anteriormente à data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compatível com o certame, e que atenderem às exigências deste edital e seus Anexos.

¹³

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
2	PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO	7.020	R\$ 23,76	R\$ 166.795,20
7	FEIJÃO CARIOQUINHA	14.060	R\$ 8,90	R\$ 125.134,00
9	ARROZ LONGO FINO	35.060	R\$ 7,81	R\$ 273.818,60
46	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	1.582	R\$ 51,51	R\$ 81.488,82
48	CACAU EM PÓ 100%	1.610	R\$ 70,80	R\$ 113.988,00
62	EXTRATO DE TOMATE	9.010	R\$ 13,20	R\$ 118.932,00
64	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	5.026	R\$ 32,89	R\$ 165.305,14
85	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM AÇÚCAR	5.244	R\$ 42,72	R\$ 224.023,68

¹⁴ Oitenta mil reais.

¹⁵ Lei Federal nº 123/2006:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: [...]

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

¹⁶ Lei Federal nº 123/2006:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: [...]

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

Nessa senda, ao relançar o processo licitatório, o Órgão Licitante deve observar as premissas traçadas a respeito do tema nos autos das Consultas TC-025129.989.20-8, TC-025128.989.20-9 e TC-025130.989.20-5¹⁷, cujo trecho de interesse importa transcrição:

“Pergunta nº 06: Em certames para a aquisição de objetos divisíveis, como efetuar a reserva de 25% do objeto para microempresas e empresas de pequeno porte, determinada pelo artigo 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/06? Aqui, a Prefeitura Municipal de Fernandópolis, observa três alternativas:

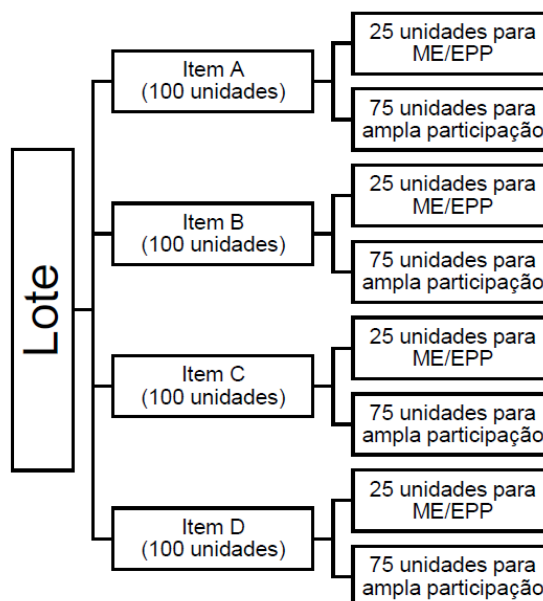
6.1) reserva de 25% do valor total orçado da licitação, separando itens que somados atinjam a percentagem legal;

6.2) divisão de cada item licitado em duas partes, uma contendo 25% e outra 75% do total que se pretende adquirir, observada a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte na menor parcela;

6.3) licitação da totalidade de cada item, deixando para as microempresas e empresas de pequeno porte interessadas a apresentação de propostas para apenas 25% do total do item, enquanto a parcela remanescente deve permanecer disponível para as demais interessadas.

Resposta: A cota de até 25% prevista pelo artigo 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/06 deve ser apurada em cada item licitado, mesmo quando o certame se realize em lotes. Assim, o certame pode ser organizado mediante divisão de cada item ou lote licitado em duas partes, uma contendo 25% e outra 75% do total que se pretende adquirir, observada a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte na menor parcela, conforme exemplificado abaixo:

¹⁷ Decisão do E. Tribunal Pleno desta Corte, de 21 de julho de 2021 (publicada no D.O.E. de 27 de agosto de 2021, transitada em julgado em 21 de setembro de 2021), de relatoria do exmo. Conselheiro Renato Martins Costa.



[...]

Pergunta nº 10: As licitações públicas realizadas por itens de valores individuais inferiores a R\$ 80.000,00, porém com valor global, representado pelo somatório dos itens, superior a tal valor, devem ser exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte?

Resposta: O artigo 48, I, da LC nº 123/06 impõe a exclusividade de participação das microempresas e das empresas de pequeno porte nos certames compostos por itens de contratação iguais ou inferiores a R\$ 80.000,00. O sentido da expressão “itens de contratação”, por sua vez, é esclarecido na redação do artigo 6º do Decreto nº 8.538/15 (aplicável na ausência de legislação local específica e mais favorável sobre a matéria), que a direcionou para os “itens” ou “lotes” autônomos sujeitos à licitação, destacando-se para exclusividade aqueles cujos valores sejam de até R\$ 80.000,00.”

Por fim, à margem do parecer, o Ministério Público de Contas questiona a adoção do procedimento auxiliar de registro de preços, aspecto não constante da inicial e para o qual não houve contraditório. Assim, em linha com recentes julgamentos plenários proferidos no TC-1250.989.24 (Rel. e. Conselheiro Robson Marinho; DJ 28/2/2024) e no TC-14393.989.24 (Rel. e. Conselheiro Dimas Ramalho; DJ 14/8/2024), cabe recomendar à origem que confira a devida atenção ao ponto suscitado pelo MPC.

Sem prejuízo da recomendação alinhavada no corpo do aresto, VOTO pela **procedência** da representação manejada por Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda., **determinando-se** à Prefeitura de Alumínio que, em querendo relançar o Pregão Presencial nº 25/2024, republique o caderno convocatório, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21¹⁸, atentando-se para as disposições da Lei Complementar nº 123/06, de forma que (i) caso verificada a ocorrência de alguma das hipóteses de exclusão do tratamento diferenciado às ME's e EPP's, vaticinadas no artigo 49, incisos II e III, do mencionado diploma legal, esta seja justificada e consignada nos documentos técnicos correlatos à licitação (Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência); ou (ii) em não ocorrendo nenhuma das referidas hipóteses excludentes, sejam observadas as diretrizes traçadas nos autos das Consultas TC-025129.989.20-8, TC-025128.989.20-9 e TC-025130.989.20-5.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB / LMN

¹⁸ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 55. § 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.